

1502002-92.2022.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ERICA PEREIRA DE SOUSA

Comarca: Itaquaquetuba

Foro: Foro de Itaquaquetuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/11/2022

... como ocorre, na maioria das vezes, com o tráfico de drogas.

9. Não é das guardas municipais, mas sim das polícias, como regra, a competência para patrulhar supostos pontos de tráfico de drogas, realizar abordagens e revistas em indivíduos suspeitos da prática de tal crime ou ainda investigar denúncias anônimas relacionadas ao tráfico e outros delitos cuja prática ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itaquaquetuba

Foro de Itaquaquetuba

1ª Vara Criminal

Estrada de Santa Isabel 1170/1194, Itaquaquetuba-SP - cep 08577-010

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502002-92.2022.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502002-92.2022.8.26.0616

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2233749/2022 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 27018047 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 2233749 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CANDIDO FERNANDES LOPES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ERICA PEREIRA DE SOUSA

Vistos.

Trata-se de processo penal promovido pelo Ministério Público contra CANDIDO FERNANDES LOPES, devidamente qualificado nos autos, pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos no artigo 33, "caput", cc o art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006, foi denunciado e está sendo processado, porque no dia 25 de agosto de 2022, por volta de 23 horas e 40 minutos, na Rua Pitangueiras, altura do nº 150, nesta cidade e Comarca, o denunciado supostamente trazia consigo e tinha em depósito, para fins de tráfico, sem autorização, 222 invólucros de cocaína (com peso de 144,3 gramas), 356 invólucros de crack (com peso 74,8 gramas) e 172

invólucros de maconha (com peso de 366,9 gramas), conforme auto de exibição e apreensão de fls. 15/16 e laudo de constatação de fls. 19/22.

Notificado às fls. 89, ofereceu defesa preliminar às fls. 92. A denúncia foi recebida fls. 95/96. Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas de acusação e, ao final, o réu foi interrogado. Em debates orais, o Ministério Público postulou pela condenação do acusado nos exatos termos da denúncia. A Defesa pugna pela improcedência da ação penal fundamentando-se na insuficiência probatória que entende ser dos autos.

É o relatório.
Fundamento e DECIDO.

A pretensão punitiva não merece ser acolhida.

A despeito da prova de materialidade delitiva estar devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante às fls. 01, pelos depoimentos às fls. 04/05, pelo auto de exibição e apreensão às fls. 06/07, pelo laudo de constatação às fls. 19/22, pelo boletim de ocorrência às fls. 42/44 e através do laudo toxicológico definitivo às fls. 126/128, a prova dos autos bem como a forma como se deu a prisão em flagrante não autorizam procedência do feito.

A testemunha MARCELO NOGUEIRA DO CARMO, guarda municipal, relatou que estava em patrulhamento ostensivo, nas imediações da Escola Municipal Virgílio Marinho, altura do nº 150, visualizaram um indivíduo em pé na calçada segurando uma mochila e ao perceber a presença da viatura saiu correndo.

Alcançado na mesma rua, em revista pessoal, foi localizado a quantia de R\$ 74,00 (setenta e quatro reais) e na mochila diversos entorpecentes, sendo 222 (duzentos e vinte e dois) invólucros de cocaína, 356 (trezentos e cinquenta e seis) invólucros de crack e 172 (cento e setenta e dois) invólucros de maconha.

Em Juízo, apresentou relato diverso do exteriorizado em solo policial. Disse que o réu estava em distância de 500 metros da escola. Disse, ainda, que a escola estava fechadas, era por volta de 23h:40min e não havia ninguém na rua. Disse que o réu carregava sacola e correu. Em seguida, disse que se tratava de uma mochila e tentou evadir-se.

A testemunha IVAN DE MOURA LIMA, guarda municipal, teceu declarações no mesmo sentido de seu colega de farda, Marcelo relatando as circunstâncias de espaço e tempo já apontadas.

Faziam patrulhamento preventivo porque havia denúncias de vandalismo no local. O réu correu da guarda municipal na posse de uma mochila pesada. Abordaram e sentiram odor muito forte vindo da mochila. Nenhum ato de traficância foi visto por parte do acusado.

O réu CÂNDIDO FERNANDES LOPES, em seu interrogatório. Conta com 38 anos. Já esteve preso por delito de homicídio e por descumprimento de medida protetiva. No dia dos fatos, os guardas municipais chegaram em sua casa. Um deles ficou na porta de sua casa e o outro ingressou em sua residência e revirou tudo o que tinha em sua casa. Foi levado para a delegacia. Não tinha nada de ilícito em sua residência. Não sabe explicar onde estavam os entorpecentes.

Passo a valorar a prova.

A narrativa da denúncia não está cabalmente comprovada. Há três versões sobre os fatos: aquela apresentada por cada um dos guardas municipais e a versão do acusado.

Os guardas municipais que afirmaram que o réu estava ao lado da escola com drogas em solo policial. Em Juízo, afirmaram que o réu estava em local de intenso tráfico de drogas em distância de 500 metros da escola.

O segundo guarda municipal não apresentou relato uníssono e afirmou que o réu - que estava próximo da escola foi não praticava qualquer ato típico de traficância, contudo, sua mochila exalava forte odor e, por esse motivo, foi abordado.

Ainda que não haja uníssono por parte dos guardas municipais, certo é que a atuação foi ilegal, já que procederam à prisão em flagrante do acusado extrapolando os limites de suas funções, já que atuaram sem visar à proteção dos bens, serviços e instalações do Município de Itaquaquecetuba (arts. 144, § 8º, da Constituição Federal e 2º, 4º e 5º, inciso II, da Lei nº 13.022/2014).

É cediço que deve existir fundada suspeita que justifique a realização de busca pessoal, de modo que deve haver elementos concretos que impliquem suspeita de prática criminosa, não sendo permitido às guardas municipais realizar busca pessoal como decorrência de atividade de investigação criminal.

No presente caso, a atuação dos guardas municipais não se baseou em nenhuma das hipóteses do art. 302 do Código de Processo Penal, mas em fatos que não chegaram nem mesmo a se tratar da famigerada "atitude suspeita" por parte do acusado. Os entorpecentes foram encontrados após realização de busca pessoal, o que constitui verdadeira atividade de investigação que extrapola as competências constitucionais e legais previstas para as guardas civis municipais.

O crime de tráfico ilícito de drogas ora imputado ao acusado, embora seja crime permanente, só foi constatado depois da revista pessoal pelos guardas civis, que não são policiais, o que evidencia a irregularidade por ausência de causa justa e prévia. Nesse cenário, tem-se que a busca pessoal foi realizada em atividade ostensiva de policiamento em via pública, o que não se coaduna com as funções dos guardas civis.

A respeito do tema, confira-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ATUAÇÃO DAS GUARDAS MUNICIPAIS. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CLARA, DIRETA E IMEDIATA COM A TUTELA DOS BENS, SERVIÇOS E INSTALAÇÕES MUNICIPAIS. IMPOSSIBILIDADE. PROVA ILÍCITA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 157 E 244 DO CPP. RECURSO PROVIDO.

1. A Constituição Federal de 1988 não atribui à guarda municipal atividades ostensivas típicas de polícia militar ou investigativas de polícia civil, como se fossem verdadeiras "polícias municipais", mas tão somente de proteção do patrimônio municipal, nele incluídos os seus bens, serviços e instalações. A exclusão das guardas municipais do rol de órgãos encarregados de promover a segurança pública (incisos do art. 144 da Constituição) decorreu de opção expressa do legislador constituinte "apesar das investidas em contrário" por não incluir no texto constitucional nenhuma forma de polícia municipal.

2. Tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil "em contrapartida à possibilidade de exercerem a força pública e o monopólio estatal da violência" estão sujeitas a rígido controle correcional externo do Ministério Público (art. 129, VII, CF) e do Poder Judiciário (respectivamente da Justiça Militar e da Justiça Estadual). Já as guardas municipais "apesar da sua relevância" não estão sujeitas a nenhum controle correcional externo do Ministério Público nem do Poder Judiciário. É de ser ver com espanto, em um Estado Democrático de Direito, uma força pública imune a tais formas de fiscalização, a corroborar, mais uma vez, a decisão conscientemente tomada pelo Poder Constituinte originário quando restringiu as balizas de atuação das guardas municipais à vigilância do patrimônio municipal.

3. Não é preciso ser dotado de grande criatividade para imaginar "em um país com suas conhecidas mazelas estruturais e culturais" o potencial caótico de se autorizar que cada um dos 5.570 municípios brasileiros tenha sua

própria polícia, subordinada apenas ao comando do prefeito local e insubmissa a qualquer controle externo. Ora, se mesmo no modelo de policiamento sujeito a controle externo do Ministério Público e concentrado em apenas 26 estados e um Distrito Federal já se encontram dificuldades de contenção e responsabilização por eventuais abusos na atividade policial, é fácil identificar o exponencial aumento de riscos e obstáculos à fiscalização caso se permita a organização de polícias locais nos 5.570 municípios brasileiros.

4. A exemplificar o patente desvirtuamento das guardas municipais na atualidade, cabe registrar que muitas delas estão alterando suas denominações para “Polícia Municipal”. Ademais, inúmeros municípios pelo país afora “alguns até mesmo de porte bastante diminuto”

estão equipando as suas guardas com fuzis, equipamentos de uso bélico, de alto poder letal e de uso exclusivo das Forças Armadas.

5. A adequada interpretação do art. 244 do CPP é a de que a fundada suspeita de posse de corpo de delito é um requisito necessário, mas não suficiente, por si só, para autorizar a realização de busca pessoal, porque não é a qualquer cidadão que é dada a possibilidade de avaliar a presença dele; isto é, não é a todo indivíduo que cabe definir se, naquela oportunidade, a suspeita era fundada ou não e, por consequência, proceder a uma abordagem seguida de revista. Em outras palavras, mesmo se houver elementos concretos indicativos de fundada suspeita da posse de corpo de delito, a busca pessoal só será válida se realizada pelos agentes públicos com atribuição para tanto, a quem compete avaliar a presença de tais indícios e proceder à abordagem do suspeito.

6. Ao dispor no art. 301 do CPP que “qualquer do povo poderá [...] prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito”, o legislador, tendo em conta o princípio da autodefesa da sociedade e a impossibilidade de que o Estado seja onipresente, contemplou apenas os flagrantes visíveis de plano, como, por exemplo, a situação de alguém que, no transporte público, flagra um indivíduo subtraindo sorrateiramente a carteira do bolso da calça de outrem e o detém. Diferente, porém, é a hipótese em que a situação de flagrante só é evidenciada após realizar atividades invasivas de polícia ostensiva ou investigativa como a busca pessoal ou domiciliar, uma vez que não é qualquer do povo que pode investigar, interrogar, abordar ou revistar seus semelhantes.

7. Da mesma forma que os guardas municipais não são equiparáveis a policiais, também não são cidadãos comuns. Trata-se de agentes públicos com atribuição sui generis de segurança, pois, embora não elencados no rol de incisos do art. 144, caput, da Constituição, estão inseridos § 8º de tal dispositivo; dentro, portanto, do Título V, Capítulo III, da Constituição, que trata da segurança pública em sentido lato. Assim, se por um lado não podem realizar tudo o que é autorizado às polícias, por outro lado também não estão plenamente reduzidos à mera condição de “qualquer do povo”; são servidores públicos dotados do importante poder-dever de proteger o patrimônio municipal, nele incluídos os seus bens, serviços e instalações.

8. É possível e recomendável, dessa forma, que exerçam a vigilância, por exemplo, de creches, escolas e postos de saúde municipais, de modo a garantir que não tenham sua estrutura física danificada ou subtraída por vândalos ou furtadores e, assim, permitir a continuidade da prestação do serviço público municipal correlato a tais instalações. Nessa esteira, podem realizar patrulhamento preventivo na cidade, mas sempre vinculados à finalidade específica de tutelar os bens, serviços e instalações municipais, e não de reprimir a criminalidade urbana ordinária, função esta cabível apenas às polícias, tal como ocorre, na maioria das vezes, com o tráfico de drogas.

9. Não é das guardas municipais, mas sim das polícias, como regra, a competência para patrulhar supostos pontos de tráfico de drogas, realizar abordagens e revistas em indivíduos suspeitos da prática de tal crime ou ainda investigar denúncias anônimas relacionadas ao tráfico e outros delitos cuja prática não atinja de maneira clara, direta e imediata os bens, serviços e instalações municipais. Poderão, todavia, realizar busca pessoal em situações absolutamente excepcionais “e por isso interpretadas restritivamente” nas quais se demonstre concretamente

haver clara, direta e imediata relação de pertinência com a finalidade da corporação, isto é, quando se tratar de instrumento imprescindível para a tutela dos bens, serviços e instalações municipais. Vale dizer, só é possível que as guardas municipais realizem excepcionalmente busca pessoal se houver, além de justa causa para a medida (fundada suspeita de posse de corpo de delito), relação clara, direta e imediata com a necessidade de proteger a integridade dos bens e instalações ou assegurar a adequada execução dos serviços municipais, o que não se confunde com permissão para realizarem atividades ostensivas ou investigativas típicas das polícias militar e civil para combate da criminalidade urbana ordinária.

10. Na hipótese dos autos, os guardas municipais estavam em patrulhamento quando depararam com o recorrente sentado na calçada, o qual, ao avistar a viatura, levantou-se e colocou uma sacola plástica na cintura. Por desconfiar de tal conduta, decidiram abordá-lo e, depois de revista pessoal, encontraram no referido recipiente certa quantidade de drogas que ensejou a prisão em flagrante delito.

11. Ainda que eventualmente se considerasse provável que a sacola ocultada pelo réu contivesse objetos ilícitos, não estavam os guardas municipais autorizados, naquela situação, a avaliar a presença da fundada suspeita e efetuar a busca pessoal no acusado.

Caberia aos agentes municipais, apenas, naquele contexto totalmente alheio às suas atribuições, acionar os órgãos policiais para que realizassem a abordagem e revista do suspeito, o que, por não haver sido feito, macula a validade da diligência por violação do art. 244 do CPP e, por conseguinte, das provas colhidas em decorrência dela, nos termos do art. 157 do CPP, também contrariado na hipótese.

12 . Recurso especial provido.

(REsp n. 1.977.119/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 23/8/2022.)

Por conseguinte, constatado que houve o desempenho de nítida atividade de investigação pelos guardas civis, que desborda da situação de flagrância, deve ser reconhecida a invalidade das provas dela decorrentes e, conseqüentemente, o réu deve ser absolvido.

Ante o exposto e tudo o mais que nos autos consta, deixo de acolher a pretensão punitiva estatal, JULGO IMPROCEDENTE o pedido do feito e, conseqüentemete, ABSOLVO o réu das imputações constantes da denúncia, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Formada a coisa julgada, arquivem-se os autos.

P. R. I.

Itaquaquecetuba, 18 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA